

1500355-53.2021.8.26.0598

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: MARÍLIA VIZZOTTO

Comarca: Barra Bonita

Foro: Foro de Barra Bonita

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... forma estável e permanente para a prática do crime de tráfico. Nesse sentido:

CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO Sentença absolutória - Quadro probatório frágil
Insuficiência de provas no tocante à associação Crime autônomo que demanda prova do
elo perene e estruturado entre os agentes para a prática da traficância Absolvição
mantida CRIME DE TRÁFICO Invasão de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barra Bonita

Foro de Barra Bonita

2ª Vara

Praça Dr. Meira, s/nº, Barra Bonita - SP - cep 17340-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500355-53.2021.8.26.0598 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500355-53.2021.8.26.0598

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e
Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

MAURO GILSON ROSOLEN JÚNIOR e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARÍLIA VIZZOTTO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia (fls. 272/275) em face de MAURO GILSON ROSOLEN JÚNIOR, VINICIUS DIAS ALVES PAZ e SAIURI DE GODOI LEME, já qualificados nos autos, imputando-lhes a prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, da Lei n.º 11.343/06 (LD), porque, supostamente, em data incerta, todavia perdurando até 09 de outubro de 2021, na cidade de Avaré/SP, os acusados, conscientes e voluntariamente, associaram-se para o fim de praticar reiteradamente o delito de tráfico de drogas. Consta, também, que no dia 09 de outubro de 2021, às 21h30min, na Rodovia SP 255, km 180, na cidade de Igaraçu do Tietê/SP, Comarca de Barra Bonita/SP, os acusados, traziam consigo e transportavam, para fins de tráfico, 01 porção de cocaína, com peso líquido de 49,32 gramas; 02 porções de crack, com peso líquido de 99,42 gramas; 02 porções de maconha, com peso líquido de 959,46 gramas, tudo sem autorização legal ou regulamentar.

Narra a exordial acusatória que Vinícius e Saiuri são moradores da cidade de Avaré/SP e, no dia dos fatos, iriam juntos até a cidade de Jaú/SP para adquirir grandes porções de drogas que seriam posteriormente fracionadas e revendidas em Avaré/SP. Ocorre que, como não possuíam automóvel próprio, Vinícius e Saiuri

contrataram Mauro como motorista, sendo ele expressamente cientificado de que a viagem até Jaú/SP tinha como principal propósito a aquisição de drogas destinadas ao tráfico. Assim é que, na data supracitada, o acusado Mauro, valendo-se de um automóvel Chevrolet/Sonic, cor preta, placas FHI-0533, transportou os acusados Vinicius e Saiuri até a cidade de Jaú/SP. Além dos acusados, estava no automóvel Polyana Silva Fernandes e Cláudia dos Santos Ferreira Alvez Paz. Na cidade de Jaú/SP, Vinicius e Saiuri receberam de pessoa não identificada as grandes porções de droga supramencionadas, que estavam acondicionadas dentro de uma bolsa. Nessas condições, quando trafegava pela rodovia que cruza a cidade de Igaraçu do Tietê/SP, o veículo acabou chamando atenção dos policiais militares, uma vez que era conduzido em alta velocidade, tinha uma película muito escura nos vidros, uma lanterna quebrada, bem como estava muito baixo, o que indicava a presença de vários ocupantes. Diante desses fatos, os policiais militares realizaram a abordagem do veículo e, durante as buscas, apreenderam a referida bolsa contendo as grandes porções de droga.

Auto de prisão em flagrante delito às fls. 01/02.

Homologada a prisão em flagrante (fls. 157/161), foi concedida liberdade provisória aos réus Polyana Silva Fernandes e Cláudia dos Santos e convertida em preventiva quanto aos réus Mauro, Vinicius e Saiuri.

A d. defesa impetrou habeas corpus (fls. 213/226), em favor dos réus, que teve sua liminar indeferida nos autos de n.º 2241912-27.2021.8.26.0000.

Houve pedido pelo Ministério Público do arquivamento dos autos quanto às investigadas Polyana e Cláudia (fls. 272/275). Na decisão de fls. 276/277 foi determinado o arquivamento dos autos em relação às investigadas, considerando a ausência de justa causa para a propositura da ação penal.

Devidamente notificados (fls. 336, 338 e 340), os acusados apresentaram defesa prévia (fls. 341/347, 410/413 e 422/428).

Em decisão de fls. 394/396 foi mantida a prisão anteriormente decretada quanto aos réus Vinicius e Saiuri. Quanto ao acusado Mauro foi concedida liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Alvará de soltura cumprido em 19/01/2022 (fls. 401/404).

Recebida a denúncia em 18/03/2022, foi designada audiência de instrução e julgamento, na modalidade virtual (fls. 433/434).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, foram interrogados os réus.

Em alegações finais, a d. representante do Ministério Público requer a procedência da pretensão acusatória nos termos da denúncia (fls. 509-516).

A d. defesa do réu Mauro, Vinicius e Saiuri, por sua vez, argumenta pela sua absolvição de ambos os delitos ou subsidiariamente pela desclassificação do delito de tráfico para o de uso de entorpecentes ou ainda para aquele previsto no art. 33, §3, LD. Teceram considerações sobre a dosimetria (fls. 528-555, 577-582 e 583-590).

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, e ausente, ainda, qualquer nulidade processual, passo ao exame do mérito.

1. Do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006

A materialidade dos fatos resta comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); termos de depoimento (fls. 03/04 e 05/06); termos de interrogatório (fls. 07, 08/09, 10, 11 e 12); boletim de ocorrência nº 5722/2021 (fls. 19/22); auto de exibição/apreensão (fls. 23/25); laudo pericial-constatação prévia (fls. 27/33); fotografias (fls. 51/53); laudo pericial definitivo (fls. 284/287); laudo pericial - objeto (fls. 289/292); relatório final do inquérito policial (fls. 258/266); bem como pela prova oral colhida.

Sobreleva notar que as substâncias apreendidas (tetrahydrocannabinol e cocaína, essa na forma de crack) se encontram expressamente previstas na Portaria n.º 344/98 e Resolução n.º 104 da Anvisa, amoldando-se perfeitamente à definição legal de droga (art. 1º, §1º, da LD).

Da mesma forma, a prova se revela idônea para ilustrar a autoria, porque o conjunto

probatório amealhado em sede judicial está em consonância com os elementos já obtidos na fase inquisitorial.

A testemunha André Luiz Pavan dos Santos, policial militar, declarou que estavam em patrulhamento e na SP 255 visualizaram o veículo sonic em alta velocidade, com insulfilme muito escuro e muito rebaixado, desconfiados, procederam a abordagem. Acabaram encostando. Viu que Vinícius, passageiro dianteiro direito, que ao sair do veículo, deixou uma bolsa no assoalho. Encontraram celulares dinheiro e na bolsa, um tijolo de maconha, crack e cocaína. No interior do veículo tinha muito cheiro de maconha. Vinícius falou que viera comprar droga em Jaú e que quem negociou a droga foi Saiuri. Mauro disse que tinha conhecimento e que foi contratado por Vinícius por 200 reais. Saiuri e demais mulheres disseram que viera à Jaú comprar calçados e passear. As 3 moças estavam no banco de trás. Cláudia e Poliana era companheira de Vinícius e de Saiuri, mas não sabe dizer qual era qual. Mauro era dono do veículo, disse que estava precisando e por isso fez o transporte. Não teve acesso ao celular de Saiuri. Não se recorda de ter achado outro pertence dentro da bolsa. A versão de Saiuri foi semelhante à de Poliana, de que vieram à Jaú passear. Só o Vinícius implicou Saiuri. Pararam cerca de 2 metros do carro, por isso visualizou. Acha que o veículo era 4 portas, não se lembra se todas foram abertas juntos. Visualizou pela diagonal, em parada tática. Todos foram cooperativos. As drogas estavam em um saco plástico.

No mesmo sentido, a testemunha Audrin de Almeida Camargo, também policial militar, aduziu que o veículo levantou suspeita por estar com uma lanterna queimada, muito rebeixado, e em alta velocidade. O veículo parou ao ser comandado. Vinicius carregava consigo uma bolsa que dispensou no assoalho. Com as pessoas foi localizado celular e dinheiro. Havia um cheiro forte de maconha. Na bolsa encontraram maconha, cocaína e crack. Mauro disse que foi contratado por Vinicius para ver buscar droga. Trouxeram as companheiras para não levantar suspeitas. Vinicius confirmou, mas disse que a negociação foi feita por Saiuri. Saiuri negou tudo e disse que vieram para comprar calçados. O cheiro de maconha era muito forte. Não se recorda de haver calçados no veículo, mas havia algo de mercado. Saiuri disse que apenas acompanhava Vinícius com sua namorada Poliana. Vinícius foi quem implicou Saiuri. Em contato com os policiais de Jaú, eles disseram que ambos são conhecidos pelo delito de tráfico. A droga estava embalada. Não indagou os presentes se usaram maconha dentro do carro. Era o terceiro homem da viatura, atrás do banco do motorista. A viatura parou atrás do veículo. Viu o Vinícius descendo e deixando a bolsa no assoalho. Vinicius foi cooperativo. Ele não chegou a dizer que a bolsa era de Saiuri.

A informante Surian Gabrielle de Godói Leme contou que sua irmã já foi presa por tráfico de drogas, mas depois que saiu não mais se envolveu com drogas, trabalhava com entrega e cuidava da filha de Vitória. No dia em questão ela tinha saído para trabalhar, mas se desviou para arrumar uma seta de moto. Ela seguia usando maconha. Saiuri trabalhava como entregadora. Morava em sua casa com a Poliana. Ela faz entrega de ifood de moto. Não sabe se Saiuri fazia trabalho em Igarapu. Não conhece Vinícius. Poliana também trabalhava com entregas. Ela saiu de moto esse dia. Depois que ela foi presa, a moto foi encontrada na casa de Cláudia. Cláudia era amiga de sua irmã. Cláudia e Vinicius tinham uma chave para apertar seta de motocicleta.

A testemunha Vitoria Cristina Ribeiro de Silva Rodrigues disse que Saiuri estava trabalhando de babá de sua filhas e fazendo entrega pelo ifood. Não sabe se fazia uso de drogas ou se era envolvida com tráfico. Antes, estava passando perto de uma viatura e por ser conhecida de uma pessoa, foi associada ao tráfico. Ao que sabe ela conhecia o casal e foi até a casa deles, Vinicius e Cláudia, que pediram que fosse a Jaú como companhia. Ficou sabendo disse pois foi até a casa dela e em contato com seus parentes, soube disso. Ao que soube o casal mexia com sapato e roupa. Esse casal venderia sapatos e veio adquiri-los. Já teve contato com a Cláudia. Cláudia, acha que vende sapatos em casa, levava na casa das pessoas, soube disso por terceiros.

A testemunha Polyana Silva Fernandes afirmou que foi convidado pela Cláudia para ir no território dos calçados, não conhecia o motorista, Mauro. Não conhecia Vinícius. Conhecia bem apenas Cláudia. Vinícius, apenas de vista. Ficou o tempo todo com

Saiuri. Saiuri não fez contato com ninguém. Saíram para trabalhar, mas a seta da moto estava estragada, passaram na casa de Cláudia, pois sempre viam eles com um carro velho e ferramentas. Aí Cláudia as convidou para ir para Jaú. Saiuri foi presa por tráfico de drogas, é usuária de maconha, mas nunca mais vendeu drogas. Trabalhavam no ifood e ela também olhava umas crianças. Saíram para trabalhar, mas acabaram desistindo após terem consertado a moto. Foram conhecer Jaú porque não conheciam, não tinham dinheiro para comprar nada. Foram chamadas pois eram amigas de Cláudia. Não compraram sapatos pois foram abordados quando chegaram na cidade. Depois foi ficando tarde e acabaram não indo ao território. Fumaram maconha na hora de voltar. Não sabe de quem era a maconha, fumaram todos juntos. Só viu a bolsa na delegacia. Quando a polícia chegou o Vinicius disse que estava ali, era uma bolsa no assoalho do passageiro. Não recebe visitas da esposa há 4 meses por questões financeiras. Não usou o celular da esposa no dia. Mauro não tinha ciência da questão da Saiuri. Quando abordados a viatura parou atrás do carro e as 4 portas foram abertas juntas, acha que não era possível visualizar nada no interior do carro. Se soubesse que Saiuri estava com drogas, não teria voltado no carro. A testemunha Richard Augusto Pires Iglesias juntou declaração à fl. 500.

O réu Mauro Gilson Rosolen Júnior, interrogado, declarou que conheceu Vinicius de uma corrida, ele perguntou se fazia viagens para fora, ele ligou uns 2 dias antes pedindo para ir para Jaú, pediu 200 reais, ele tinha falado que só ia ele e a mulher. Depois ele ligou e pediu para ir de tarde. Quando chegou Poliana e Saiuri estavam arrumando a seta da moto. Ele não havia lhe avisado que elas iam juntas. Ele disse que ela iriam juntas. Chegando em Jaú foram parados pela PRF, falou que iam ao território de calçados. Aí descobriu que Vinicius tinha passagem. No meio do percurso Vinicius comentou que ia pegar uma pequena quantidade de maconha, mas era para curtir o passeio. Pararam em uma rua que já não sabe onde é, foi usar o banheiro e quando voltou vinicius estava entrando no carro. Pararam no posto e no mercado. Não se importou que Vinicius fumasse. Logo foram parados. Não sabe dizer porque o território dos calçados estava fechado no horário. Ia lavar o carro no dia seguinte, por isso não se importou que fumassem. Não viu quando vinicius pegou esses baseados. Quem lhe direcionava eram as meninas do banco de trás, mas não sabe dizer quem, mesmo para esse local, em que Vinicius pegou o baseado, o direcionamento veio do banco de trás. A Cláudia não era, pois tem uma voz mais grossa. Não viu Vinicius com sacola. Uma viatura parou ao lado deles, na transversal e ao lado havia outra viatura. Todos abriram a porta ao mesmo tempo. Quem determinou o horário da viagem foi o Vinicius. Não sabia que o território fechava às 17h nessa época de pandemia. Não soube justificar porque não colocou o território de calçados como destino final e só colocou a cidade de Jaú. Não sabe dizer o que as mulheres fizeram juntas no mercado. Reafirma que não viu a bolsa. A bolsa foi achada dentro do veículo. Não tem amizade com Vinicius e a esposa. Nunca veio à Jaú. Nega que tenha dito aos policiais que foi contratado por Vinicius para buscar drogas em Jaú. Não aceitaria se soubesse.

Em seu interrogatório, Vinicius Dias Alves Paz disse que estava no veículo, mas não estava transportando as drogas, não sabe se era de Saiuri, nem chegou a visualizar ela dentro do carro. Veio para Jaú com a esposa, para pesquisar preços de sapatos, ela ia comprar tênis para as crianças. Na delegacia realmente falou a verdade, Mauro veio como motorista, lhe cobrou 200, tinham um carro com problema. A viagem ia compensar para comprar os tênis. Deu carona para Saiuri, sabia que ela iria comprar drogas. Ela voltou com a mochila e a colocou atrás do banco do passageiro. Consumiram no carro um baseado bolado. Acha que Mauro soube por cima sobre as drogas. Saiuri realmente esteve em sua casa levando a moto para consertar. Nesse dia ela o viu arrumado, e pediu para ir junto. Nega que a bolsa estivesse consigo no carro. Não sabe porque os policiais lhe acusariam. Saiuri não ficou o tempo todo com Poliana.

A ré Saiuri de Godoi Leme contou que admite o delito. Estava indo para trabalhar, mas a seta da moto estava estragada, já tinha visto Vinicius e Cláudia consertando carro, foram lá e arrumaram a seta, foi convidada para passear e ir ao MC Donalds. Chegando em Jaú foram abordados, se perderam, após foram ao posto e ao supermercado. Não foram ao território e nem no MC. Saíram umas 3 ou 4 horas de

Avaré. Não viu a bolsa no carro, só viu no momento que a polícia achou. Vinicius tinha um baseado, ele passou para trás ele já acesso. Pretendiam voltar de Jaú no mesmo dia. Mauro também consumiu o baseado. Quando viu já tinham 3 ou 4 viaturas lhe abordaram em igaraçu, não abriram todas as portas ao mesmo tempo, primeiro saiu o da frente. No início foi abordada pela polícia rodoviária, depois foi os que os prenderam. A informação que ela comprara as drogas não procede. Hoje acha que foi convidada para que lhe imputassem as drogas caso fossem achadas. Não conhece ninguém em Jaú. É usuário de maconha, mas usa só socialmente. Sempre trabalhou. No entanto, as narrativas dos réus, não encontram amparo nas demais provas produzidas. Os depoimentos das testemunhas policiais, coerentes e harmônicos entre si, deixam isoladas as versões dos réus, que, por isso, não são suficientes para incutir dúvida razoável.

Não há motivos para não dar créditos à palavra dos policiais que atuaram no caso, conforme a jurisprudência do C. STJ (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) e do E. TJSP (TJSP; Apelação Criminal 0014180-58.2012.8.26.0565; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavalcheiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Caetano do Sul - 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro: 15/05/2019). Não constam rixas envolvendo os réus e essas testemunhas, que, inclusive, foram devidamente compromissadas em juízo, nos termos do art. 203 do CPP. Destaque-se que a prova foi colhida ao crivo do contraditório, consoante art. 5º, LV, da CF.

Ademais, os policiais foram enfáticos ao afirmarem, em juízo, que visualizaram o veículo dos acusados sendo conduzido em alta velocidade. Além disso, durante as buscas no interior do automóvel apreenderam uma bolsa contendo as drogas com os acusados.

A autoria há de ser atribuída aos réus em conjunto pois tenho que ficou substancialmente comprovado, seja pelo depoimento dos policiais, seja pelas contradições das versões trazidas pelos réus, que os três sabiam que no veículo transportavam as drogas e aderiram a essa conduta. Além da confissão feita por todos de que no veículo já tinham consumido parte da maconha, não é crível que Vinicius e a esposa tenham contratado um uber para ir até outra cidade apenas para pesquisar preços de calçados (pois a economia no preço de 3 calçados, seria menor que o preço da viagem), ou se fossem compra-los, teriam convidado outras duas pessoas que nada comprariam, apenas tomando espaço do veículo que seria usado para trazer essas mercadorias. Em reforço, não se revela crível, tampouco que vendedores de calçados não tivessem colocado como destino da viagem o Território de Calçados ou que não tivessem pesquisado seu horário de funcionamento.

De outro lado, o depoimento de Vinicius é de que Saiuri seria a pessoa que veio negociar as drogas em Jaú, tendo sido ela a fornecer a direção ao motorista, sendo que ele sabia que Saiuri iria comprar e depois transportar no carro essas drogas. Os policiais, por sua vez, afirmam que as drogas estavam com Vinicius quando da abordagem.

Em reforço, Vinicius, perante o delegado de polícia disse que "que foi procurado por SAIURI para arrumar um veículo e motorista para trazê-la a Jaú, onde a mesma viria buscar drogas que iria vender, que então ajeitou a pessoa de MAURO para fazer o serviço, mas MAURO ficou com receio de trazer SAIURI sozinho e por isso pediu para o depoente acompanhá-lo (...) que SAIURI foi até a rua ao lado desse mercado e dali voltou com uma bolsa, enquanto o interrogado e MAURO aguardavam e depois disso seguiram para voltarem para AVARÉ que nem chegaram a ir ao território do calçado, e na estrada foram abordados pelos policiais, que acreditam que a mochila devesse estar debaixo do banco do carro, quando os policiais encontraram, visto que SAIURI estava no banco de trás." (fl. 7)

Mauro, em delegacia, também admitiu que sabia e anuiu ao transporte de drogas, tendo apresentado a justificativa de necessidade econômica, essa que apenas seria necessária se tivesse mesmo concordado com o transporte das substâncias. Disse ainda que fora Vinicius o negociador das drogas: "depoente disse que sim que VINICIUS narrou que iria pegar uma pequena quantidade de drogas, mas como esta sendo processado por uma dívida de pensão, precisava do dinheiro e que o dinheiro que

tinha consigo era dos duzentos reais da corrida que fez para VINICIUS, que pegou VINICIUS e as mulheres na casa dele (...) num local onde parecia um bar, VINICIUS mandou parar, que o interrogado desceu para urinar e viu quando VINICIUS retornava, entrando no carro com uma bolsa, que não procuraram pelo território do calçado" (fl. 8-9)

Cabe ressaltar que, a grande variedade e a quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 50g de cocaína, 100g de crack e quase 1kg de maconha) seriam suficientes para a produção de diversas porções individuais para a venda.

Outrossim, as circunstâncias do flagrante, a quantidade e natureza das drogas apreendidas em posse dos acusados, bem como os depoimentos colhidos em juízo indicam que os entorpecentes não se destinavam ao consumo pessoal, e sim à mercancia (art. 28, § 2º, da LD).

Ressalto que conforme Estudo Técnico para sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da lei n. 11.343/2006, do MPPR disponível em (https://site.mppr.mp.br/arquivos/File/Projeto_Semear/Consultas/Consulta_01_2019/Estudo_Tecnico_final_NUPECRIM.pdf) a quantidade compatível com o uso diário de cocaína é em média 3,8 gramas por dia, a de maconha não passa de 2,5g e a de crack 1,5g.

Dessa forma, tenho que as condutas praticadas pelos acusados amoldam-se ao delito de tráfico de drogas, uma vez que praticaram os núcleos "trazer consigo" e "transportar" e, em se caracterizando a figura do art. 33 da LD como tipo misto alternativo, a prática de qualquer de seus verbos é apta a configurá-lo.

Presente a atenuante da confissão quanto aos réus Mauro e Vinicius, considerando que os acusados admitiram a traficância, ainda que em sede policial (art. 65, III, d, do CP e Súmula 545 do STJ).

Concorre a minorante do art. 33, §4º, da LD, uma vez que os réus Mauro e Saiuri são primários, com bons antecedentes (fls. 128/129 e 136/138), incidindo em seus favores a presunção de que eles não se dedicam a atividades criminosas, uma vez que não há elementos nos autos que a infirmem, cabendo ressaltar que nenhum dos acusados possuem registros de atos infracionais. Ademais, não se pode concluir que estavam em associação para o tráfico, conforme será abordado no próximo tópico. Nesse sentido, a jurisprudência do C. STF:

(...) A previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. Conforme assentado na doutrina: "A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena". (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas . 2016. p. 50). E também: "(...) militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, nesse caso, é do Ministério Público (...)". (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de Drogas anotada . 2009. p. 109). Tecidas as considerações pertinentes e preenchidas as condições do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, tem a paciente o direito à redução, uma vez que se cuida de ré primária, tem bons antecedentes e não há qualquer indicação de envolvimento em efetiva organização criminosa. HC 154694 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020).

A fração de diminuição será a de 2/3, por inexistirem circunstâncias que justifiquem a redução em menor patamar.

Destarte, promovo a emendatio libelli, com fulcro no art. 383 do CPP, para que a

capitulação do delito conste como a do art. 33, caput e §4º, da LD.

Por outro lado, quanto ao réu Vinicius presente a agravante da reincidência, pois o réu sofreu uma condenação com trânsito em julgado nos autos de n.º 0001741-92.2016.8.26.0106 (fls. 134/135), não tendo transcorrido cinco anos entre a extinção da pena e a data dos fatos processados na presente demanda (arts. 61, I, e 63 do CP). Além disso, não se aplica a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da LD, pois o réu é reincidente. Não concorrem majorantes.

2. Do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006

Quanto ao crime previsto no art. 35 da LD, não vislumbro a existência de materialidade. Não restou demonstrado pela prova produzida que haveria associação estável e duradoura, com vinculação sólida, constituída para o fim de praticar uma série indeterminada de crimes.

O topo do art. 35 desta lei dispõe: "associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei". O tipo objetivo do art. 35 pune a associação para o tráfico (prescindindo, portanto, da concretização do tráfico), ao passo que o tipo subjetivo consiste no dolo específico de se associar, de forma permanente ou estável, para praticar tais crimes. A estabilidade e a permanência do pacto são essenciais conforme consolidado pelas decisões dos tribunais. O objeto material e jurídico é a paz pública.

A presente ação penal versa sobre a configuração do delito do artigo 35 da aludida lei. E, para a configuração de tal delito, não basta que o réu esteja ligado a "atividades criminosas" (expressão usada pelo art. 33, §4º), sendo necessário demonstrar de forma sólida que havia uma associação organizada de forma estável e permanente para a prática do crime de tráfico. Nesse sentido:

CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO Sentença absolutória - Quadro probatório frágil Insuficiência de provas no tocante à associação Crime autônomo que demanda prova do elo perene e estruturado entre os agentes para a prática da traficância Absolvição mantida CRIME DE TRÁFICO Invasão de domicílio Ilicitude das provas Inocorrência Crime permanente Preliminar afastada - Quadro probatório seguro e coeso a evidenciar autoria e materialidade do delito Depoimentos de policiais militares Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas Análise que se faz em cada caso concreto Inexistência de dúvida que justifica o decreto condenatório Pena correta Réu reincidente Ré primária Redutor concedido à ré Regimes corretos Recursos improvidos" (TJSP; Apelação Criminal 0001360-41.2017.8.26.0594; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/04/2019; Data de Registro: 22/04/2019). HABEAS CORPUS. ART. 35, DA LEI N. 11.343/2006. NECESSIDADE DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MERO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 2. O acórdão impugnado, ao concluir pela condenação do paciente e do corréu pelo crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, em momento algum fez referência ao vínculo associativo estável e permanente porventura existente entre eles, de maneira que, constatada a mera associação eventual entre os acusados para a prática do tráfico de drogas - sem necessidade de reavaliação probatória ou exame de fatos - , devem ser absolvidos do delito em questão. 3. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para absolver o paciente do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, com extensão dos efeitos desse decisor para o corréu, a teor do art. 580 do CPP." (STJ - HC: 270837 SP 2013/0159054-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/03/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2015).

Entendo que as circunstâncias da apreensão não possui, por si só, carga probatória

suficiente a embasar um pleito condenatório de associação para o tráfico, tipo que exige relação estável e permanente entre duas pessoas, com o fim de praticar série indeterminada de crimes de tráfico. No caso vertente, não há prova suficiente de que os acusados teriam se associado de forma minimamente durável a justificar a condenação.

Cabe frisar que, no caso dos autos, embora seja certo o concurso de pessoas, bem como esteja bem caracterizado nos autos o propósito de destinação dos entorpecentes ao consumo de terceiros, não há prova suficiente da estabilidade e permanência para configuração do crime de associação para o tráfico.

Desta forma, o Ministério Público não se desincumbiu no tocante à imputação pela associação para o tráfico, principalmente por não demonstrar o vínculo ilícito estável e permanente entre os agentes.

Assim, a absolvição dos acusados pela imputação da associação, com base no art. 386, II, do CPP, é medida que se impõe.

Verifico que, na data dos fatos, os acusados eram imputáveis, tinham potencial consciência da ilicitude de seus comportamentos e lhes eram exigíveis condutas diversas. A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que os acusados efetivamente praticaram os fatos descritos na denúncia, razão pela qual devem responder criminalmente pelo ocorrido.

Em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), o qual se respalda no critério trifásico proposto por Nelson Hungria e adotado no art. 68 do CP, passo à dosimetria das penas.

Da dosimetria da pena do réu Mauro Gilson Rosolen Júnior

Na primeira fase (arts. 59 do CP e 42 da Lei n.º 11.343/2006), identifico que a culpabilidade é intrínseca ao tipo penal. O réu tem bons antecedentes (fls. 128/129). Não há elementos concretos acerca de sua conduta social e personalidade.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são comuns à espécie. Não há que se falar em comportamento da vítima, pois o crime é vago. A quantidade e a diversidade de droga devem ser sopesadas em conjunto, e a despeito da variedade dos entorpecentes, foi apreendido o crack, substância com efeitos especialmente deletérios e grande poder viciante. Assim, aumento a pena em 1/8. Dessa forma, fixo a pena base em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP e Súmula 545 do STJ), reduzo a pena no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, concorre a minorante do art. 33, § 4º, da LD, razão pela qual diminuo a pena em 2/3, resultando em pena de 1 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias- multa.

Assim, deve Mauro Gilson Rosolen Júnior ser definitivamente condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias- multa.

De acordo com a atual redação do § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Da leitura do aludido dispositivo legal, infere-se que a detração, na sentença condenatória, será necessária quando, descontado da pena definitiva fixada o tempo em que o réu ficou preso ou internado provisoriamente, houver mudança no regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, com o nítido escopo de evitar a continuidade da imposição de indevido regime mais gravoso, facilitando aos sentenciados a primeira progressão de regime. Entretanto, no caso dos autos, o réu respondeu o processo em liberdade. Por conseguinte, deixo de proceder à detração.

O regime inicial será o aberto, com fundamento no art. 33, § 2º, c, do CP, diante das circunstâncias judiciais favoráveis preponderantes.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do acusado, fixo o valor do diamulta em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (arts. 49, §§ 1º e 2º, e 60, caput, do CP e art. 43 da Lei n.º 11.343/2006).

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, do CP), quais sejam, prestação de

serviços à comunidade e limitação de fim de semana (arts. 43, IV e VI, do CP), a serem especificadas pelo juízo da execução.
Substituída a pena e também em razão do seu quantum, incabível o sursis penal (art. 77, caput e § 3º, do CP).

Da dosimetria da pena do réu Vinicius Dias Alves Paz

Na primeira fase (arts. 59 do CP e 42 da Lei n.º 11.343/2006), identifico que a culpabilidade é intrínseca ao tipo penal. O réu possui maus antecedentes, porque reincidente, mas deixo de valorá-los nesta fase para não incorrer em bis in idem (Súmula 241 do STJ). Não há elementos concretos acerca de sua conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são comuns à espécie. Não há que se falar em comportamento da vítima, pois o crime é vago. A quantidade e a diversidade de droga devem ser sopesadas em conjunto, e a despeito da variedade dos entorpecentes, foi apreendido o crack, substância com efeitos especialmente deletérios e grande poder viciante. Assim aumento a pena em 1/8. Dessa forma, fixo a pena base em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa.

Na segunda fase, o réu é reincidente (fls. 134/135). Sofreu uma condenação transitada em julgado (autos de n.º 0001741-92.2016.8.26.0106), não tendo decorrido cinco anos após o cumprimento da pena imposta (art. 61, I, e 63 do CP). Porém, confessou a prática do crime, circunstância que não pode ser desprezada na dosimetria da pena (art. 65, III, d, do CP e Súmula 545 do STJ). Assim, na segunda fase, mantenho a pena anteriormente fixada.

Na terceira fase, ausentes majorantes e minorantes, converto a pena provisória em definitiva.

Assim, deve Vinicius Dias Alves Paz ser definitivamente condenado a 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa.

De acordo com a atual redação do § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Da leitura do aludido dispositivo legal, infere-se que a detração, na sentença condenatória, será necessária quando, descontado da pena definitiva fixada o tempo em que o réu ficou preso ou internado provisoriamente, houver mudança no regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, com o nítido escopo de evitar a continuidade da imposição de indevido regime mais gravoso, facilitando aos sentenciados a primeira progressão de regime. Entretanto, no caso dos autos, embora o réu tenha permanecido, por algum tempo, preso processualmente, vislumbro que a detração em nada alterará o regime fixado, haja vista que o réu é reincidente e que eventual mudança de regime decorreria da progressão e não do instituto da detração. E a mudança de regime por progressão deve ser procedida no Juízo da Execução. Por conseguinte, deixo de proceder à detração.

O regime inicial será o fechado, com fundamento no art. 33, § 2º, a, do CP, e em virtude da reincidência.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (arts. 49, §§ 1º e 2º, e 60, caput, do CP e art. 43 da Lei n.º 11.343/2006).

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), tampouco ao sursis penal (art. 77 do CP), em razão do quantum da reprimenda e da reincidência em crime doloso.

Da dosimetria da pena da ré Saiuri de Godói Leme

Na primeira fase (arts. 59 do CP e 42 da Lei n.º 11.343/2006), identifico que a culpabilidade é intrínseca ao tipo penal. A ré tem bons antecedentes (fls. 136/138). Não há elementos concretos acerca de sua conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são comuns à espécie. Não há que se falar em comportamento da vítima, pois o crime é vago. A quantidade e a diversidade de droga devem ser sopesadas em conjunto, e a despeito da variedade dos entorpecentes, foi apreendido o crack, substância com efeitos especialmente

deletérios e grande poder viciante. Assim, aumento a pena em 1/8. Dessa forma, fixo a pena base em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, fica mantida a pena intermediária no mesmo patamar.

Na terceira fase, concorre a minorante do art. 33, § 4º, da LD, razão pela qual diminuo a pena em 2/3, resultando em pena de 1 ano e 10 meses e 15 dias de reclusão e 187 dias- multa.

Assim, deve Saiuri de Godói Leme ser definitivamente condenada a 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão e 187 dias- multa.

De acordo com a atual redação do § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Da leitura do aludido dispositivo legal, infere-se que a detração, na sentença condenatória, será necessária quando, descontado da pena definitiva fixada o tempo em que o réu ficou preso ou internado provisoriamente, houver mudança no regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, com o nítido escopo de evitar a continuidade da imposição de indevido regime mais gravoso, facilitando aos sentenciados a primeira progressão de regime. Entretanto, no caso dos autos, embora a ré tenha permanecido, por algum tempo, presa processualmente, vislumbro que a detração em nada alterará o regime fixado, de maneira a mostrar-se mais adequado que ela seja procedida no Juízo da Execução para cômputo de pena cumprida.

Por conseguinte, deixo de proceder à detração.

O regime inicial será o aberto, com fundamento no art. 33, § 2º, c, do CP, diante das circunstâncias judiciais favoráveis preponderantes.

Ausentes elementos sobre a condição econômica da acusada, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (arts. 49, §§ 1º e 2º, e 60, caput, do CP e art. 43 da Lei n.º 11.343/2006).

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, do CP), quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana (arts. 43, IV e VI, do CP), a serem especificadas pelo juízo da execução.

Substituída a pena e também em razão do seu quantum, incabível o sursis penal (art. 77, caput e § 3º, do CP).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, , para, com fulcro no art. 383 do CPP:

a) CONDENAR MAURO GILSON ROSOLEN JÚNIOR, já qualificado, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 1 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias- multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana;

b) CONDENAR VINICIUS DIAS ALVES PAZ, já qualificado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 562 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa;

c) CONDENAR SAIURI DE GODÓI LEME, já qualificada, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 187 dias- multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana;

d) ABSOLVER MAURO GILSON ROSOLEN JÚNIOR, VINICIUS DIAS ALVES PAZ e SAIURI DE GODÓI LEME, já qualificados, da imputação da prática do delito do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, com fundamento no art. 386, II, do CPP.

Revogo a prisão preventiva, quanto a ré Saiuri, porque o regime fixado e a substituição da pena são incompatíveis com a custódia cautelar (arts. 387, § 1º, e 312 do CPP), conforme precedentes dos Tribunais Superiores (STF, HC 167681 AgR,

Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2020 PUBLIC 28-02-2020; STJ, HC 467.949/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 20/02/2020). Expeça-se alvará de soltura, colocando-se a ré em liberdade, salvo se estiver presa por outro motivo.

Quanto ao réu Mauro não houve alteração fática que justifique a imposição de prisão preventiva (arts. 387, § 1º, e 312 do CPP).

Mantenho a prisão preventiva (art. 387, § 1º, do CPP) do réu Vinicius, porquanto inalteradas as condições que a justificaram, bem como presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Necessário o recolhimento do acusado ao cárcere para resguardar a ordem pública, uma vez que, além de estar sendo condenado pelo crime de tráfico, é reincidente, já tendo sido condenado pelo crime de roubo. Assim, tenho que a adoção de medidas cautelares diversas da prisão se revelariam insuficientes para impedir a reiteração criminosa. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Expeça-se guia de execução provisória.

Custas pelos réus, nos termos do art. 804 do CPP, observada eventual gratuidade judiciária.

Oficie-se à autoridade policial, autorizando a incineração das drogas, se ainda não ocorreu, devendo o fato ser certificado nos autos (art. 72 da LD).

Como a quantia e os objetos apreendidos estão intrinsecamente vinculados à prática delitiva – produto e instrumentos da mercancia da droga –, declaro seu perdimento em favor da União, devendo ser transferida a quantia para o FUNAD (art. 91, II, do CP).

Expeça-se certidão de honorários, caso os patronos dos réus tenham sido nomeados com base no convênio OAB/Defensoria.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao IIRGD, comunicando as condenações;
- b) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;
- c) proceda-se ao recolhimento dos valores atribuídos a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP;
- d) expeçam-se guias de execução definitiva;
- e) após o cumprimento de todas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

A inscrição em livros de registro do rol dos culpados foi abolida, conforme art. 372 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

Sentença registrada eletronicamente.

Publique-se.

Intimem-se.

Barra Bonita, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA